

1501634-26.2022.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... de que o réu Gabriel praticava o tráfico de entorpecentes. Os policiais apenas afirmaram que ele seria "olheiro" e não relatam que houve ato de comércio ou auxílio à prática do comércio ilícito, sendo tal conduta atípica. Pleiteia, ainda, a desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas ou o delito previsto no artigo 37 da mesma Lei. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1501634-26.2022.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501634-26.2022.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA e outro

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

EDVALDO DE LIMA e GABRIEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 2 de maio de 2022, por volta das 17h00min, na Rua João Soares Rosa, esquina com Rua Antônio Bergamini Sândalo, nesta cidade e Comarca, em concurso, conluiados e com unidade de propósitos com o adolescente G. V. R., de 15 anos de idade (fl. 14), traziam consigo e guardavam, para entrega e consumo de terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 7,66 gramas de cocaína, divididos em noventa e dois invólucros, 55,68 gramas da mesma droga, divididos em cento e vinte e nove invólucros, e 20,75 gramas de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, divididos em vinte e dois invólucros (fls. 51/52 e 147/151).

Presos em flagrante delito (fl. 5), a prisão foi convertida em preventiva (fls. 79/82). Os réus foram notificados (fl. 203 e fl. 205) e apresentaram defesa

preliminar (fls. 209/210). A denúncia foi recebida em 11/8/2022 (fls. 214/216) e os acusados foram citados (fl. 253 e fl. 255).

Em audiência de instrução e julgamento virtual, realizada em 13/9/2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum e os réus foram interrogados (fls. 250/251).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia. Na fixação da pena do réu Edvaldo devem ser valorados os maus antecedentes e a reincidência, que implica em exasperação da pena base, impedem a caracterização da figura do tráfico privilegiado e impõem a fixação do regime inicial fechado. Em relação ao réu Gabriel, embora primário, verifica-se já ter sido processado pela prática de atos infracionais, razão pela qual a pena base deve ser fixada além do mínimo legal. Presente a atenuante da menoridade relativa. O prévio envolvimento com delitos também impede a caracterização do tráfico privilegiado em impõe a fixação do regime inicial fechado, para o cumprimento da pena. Por fim, requer a perda em favor da União dos bens e numerário apreendidos.

Em alegações finais, a Defesa do réu Edvaldo argumenta que não há provas suficientes e nem ao menos indícios de que os ilícitos apreendidos pertencessem ao sentenciado. Sustenta que os relatos dos policiais são contraditórios e não corroboram com as demais provas dos autos, além de nada de ilícito ser encontrado em poder do sentenciado, sendo de rigor a absolvição por falta de provas (fls. 256/263).

A Defensoria Pública, às fls. 266/275, sustenta que não há provas suficientes de que o réu Gabriel praticava o tráfico de entorpecentes. Os policiais apenas afirmaram que ele seria "olheiro" e não relatam que houve ato de comércio ou auxílio à prática do comércio ilícito, sendo tal conduta atípica. Pleiteia, ainda, a desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas ou o delito previsto no artigo 37 da mesma Lei. Além disso, requereu o afastamento da agravante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, posto que a denúncia não apresenta de forma pormenorizada a ligação entre o adolescente e cada um dos acusados e a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, com fixação do regime aberto e conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelas provas colhidas durante a instrução, tais como o auto de prisão em flagrante (fl. 5), boletim de ocorrência (fls. 35/38), auto de exibição e apreensão e fotos (fls. 41/42 e fls. 43/46), fotos (fls. 47/48), pelos laudos de constatação provisória e de exame químico-toxicológico - definitivo (fls. 50/52 e fls. 147/151), este atestando a natureza da substância apreendida (Cocaína e tetrahydrocannabinol) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Marli Ribeiro Augusto e Wellington Corredato da Silva, policiais civis, declaram terem recebido informações de que estava ocorrendo tráfico de drogas em um local no Jardim Renata, próximo a um posto de saúde. Eles se dirigiram até o local e observaram que, de fato, o réu Edvaldo estava comercializando entorpecentes, com a ajuda do réu Gabriel e do adolescente G. V. R. O réu Edvaldo permanecia nas proximidades de um corredor ao lado de um posto de saúde. Ele tinha em suas mãos uma sacola verde, que eventualmente era escondida em uma mata próxima.

O réu Gabriel e o adolescente G. V. R. atuavam como “olheiros” em cruzamentos próximos, realizando também o primeiro contato com os usuários. Eles retornaram ao local no mesmo dia, na parte da tarde, e em breve campanha viram o trio atender dois usuários, um que chegou de bicicleta e o outro a pé. Eles inicialmente falaram com o adolescente G. V. R., que repassou a informação ao réu Edvaldo, que entrou na mata e retornou com a sacola. Após algum tempo, eles realizaram um cerco. O réu Gabriel e o menor foram abordados no local dos fatos e o réu Edvaldo foi localizado em um bar próximo. Com Edvaldo foi encontrada apenas a quantia de R\$ 26,00. No local em que eles viram Edvaldo se abaixar, no matagal, havia uma sacola verde com 22 porções maconha, 129 “pinos” de cocaína e 90 pedras de crack. O adolescente G. V. R. confessou trabalhar como “olheiro”, mas não quis dizer para quem. Gabriel e Edvaldo negaram a prática do delito.

O réu Edvaldo de Lima, interrogado, negou a prática do delito. Declarou que na data dos fatos era aniversário da prima da sua esposa, razão pela qual se dirigiu ao Jardim Renata. Ele foi em uma mercearia para comprar produtos para a festa, que foram armazenados em uma sacola verde. Decidiu comprar duas porções de maconha. Estava em um bar bebendo cerveja e consumindo a droga quando foi preso pela polícia.

O réu Gabriel Henrique Barbosa da Silva, interrogado, também negou a prática do delito. Disse ser dependente químico e que na data do fato comprou crack do adolescente G. V. R.. Entrou em um matagal e, quando consumia a droga, ocorreu a operação da polícia civil.

Não obstante a negativa dos acusados e os argumentos defensivos, a atividade delitiva restou delineada e corroborada com a existência de elementos bastantes que demonstram que as porções apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) as informações prévias de que ocorria comércio ilícito no local dos fatos, seguida de campanha que definiu as funções da atividade delitiva e flagrou a venda de entorpecentes para usuários no próprio local; b) a localização, em meio ao matagal, no qual o réu Edvaldo foi avistado se abaixando, de uma sacola contendo 22 porções maconha, 129 “pinos” de cocaína e 90 pedras de crack; c) a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, embalados individualmente (foto de fl. 43) e prontos para entrega e venda a terceiros;

A prova coligida, por sua vez, é robusta e sustenta o decreto condenatório.

Com efeito, os policiais civis afirmaram de forma uníssona que havia informações de traficância em certo local do Jardim Renata. Fizeram observação de toda a movimentação, notando que o réu Edvaldo se posicionava perto de um corredor do posto de saúde e trazia nas mãos uma sacola com entorpecentes que, eventualmente, ficava escondida em uma mata próxima. Já o réu Gabriel e o adolescente agiam como “olheiros” e realizavam o primeiro contato com os usuários.

Em que pesem os argumentos defensivos, os relatos dos policiais tem respaldo probatório nos autos, pois a campanha permitiu observar que, com a aproximação de usuários, o réu Edvaldo abaixava-se num matagal próximo, onde foi localizada, posteriormente, a sacola de entorpecentes, a mesma que avistaram em sua mão conforme imagem de fl. 48.

A par disso, sua narrativa de que dentro da sacola plástica estavam itens para uma festa de aniversário não restou comprovada nos autos.

Da mesma forma, a função do réu Gabriel foi visualizada durante a campanha pelos policiais, os quais notaram que agia na companhia do adolescente como “olheiro” nas proximidades, bem como fazendo o primeiro contato com usuários, encaminhando-os em

seguida ao réu Edvaldo.

O fato de não portarem a droga no momento da abordagem não exclui a traficância, pois é sabido que para não levantar suspeitas e evitar a apreensão, o entorpecente é acondicionado no meio do matagal, em terrenos baldios e de lá retirado somente com a aproximação de usuários.

A conduta de ambos os acusados foi acompanhada pelos policiais que não fizeram uma abordagem aleatória, mas sim precedida de informações e de campana, permitindo a visualização do primeiro contato com usuários feito pelo réu Gabriel e o atendimento efetivo de venda realizado pelo acusado Edvaldo. Inclusive, os policiais registraram fotos dos réus no local dos fatos, na posse da sacola verde em que as drogas estavam acondicionadas (fls. 47/48).

Também não exime o sentenciado Edvaldo de responder pela traficância o fato de não ser abordado no local do cerco, visto que os policiais relatam que o bar no qual foi abordado era próximo ao ponto de venda de drogas.

E, certamente, toda a sua atividade foi acompanhada pelos agentes públicos tanto que foi localizado imediatamente após o cerco.

O fato é que diante das provas orais e documentais constantes dos autos, as versões dos acusados devem ser apreciadas com reserva, especialmente porque restaram completamente isoladas. Já em relação aos testemunhos dos policiais, destaco que seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, prestam conta de suas atividades, não havendo qualquer motivo para que incriminassem falsamente os detidos.

Inviável a desclassificação pleiteada pela Defesa para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/2006), vez que os acusados não fazem prova de que foram abordados com porção de maconha ou "crack" restante de eventual consumo. Tal tese está sustentada apenas nos relatos dos sentenciados, que devem ser apreciados com reserva, não havendo em relação ao sentenciado Gabriel qualquer comprovação dos períodos de internação noticiados (fl. 22). E mesmo que os réus sejam usuários, esse fato, por si só, não afasta de forma automática a traficância, pois nada impede que façam uso de entorpecente e também venda drogas a terceiros.

Outrossim, em que pese a combativa Defesa pleitear a desclassificação do delito imputado ao acusado Gabriel para àquele previsto no artigo 37 da Lei de Drogas, nada há nos autos que demonstre que sua função limitava-se a colaborar com informações para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes ou, ainda, que se tratava de mero "olheiro" do local.

Como a prova oral demonstrou, o acusado fazia o atendimento prévio dos usuários, levando-os para a aquisição do entorpecente com o réu Edvaldo.

O tipo penal descrito pelo artigo 37 da Lei Antidrogas incrimina aquele que atua como informante de eventual grupo destinado à prática do tráfico de drogas, não se aplicando àquele que colabora material e diretamente com a venda dos entorpecentes, como no caso dos autos, no qual o acusado manteve contato direto com o comércio ilegal e agiu como verdadeiro coautor, a teor do disposto no artigo 29 do Código Penal.

Desde logo, ressalto que incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06 visto que comprovada a participação do menor G. V. R., de 15 anos de idade (fl. 14), flagrado nas mesmas funções do réu Gabriel, ou seja, agindo como "olheiro" e conduzindo os usuários até o réu Edvaldo, que cuidava do

entorpecente comercializado. Ao contrário do aduzido pela Defesa, a denúncia descreve a ligação dos réus com o adolescente, restando evidente que o envolveram no comércio ilícito, agindo o menor ativamente na empreitada criminoso.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes em relação aos acusados, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade dos agentes, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Em relação ao réu Edvaldo de Lima, considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, ponderando, ainda, a quantidade de entorpecente apreendida e os maus antecedentes (processo nº 0002875-64.2010.8.26.0495 – pena extinta em 17/4/2012 – fls. 62/63), exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não há nos autos outros elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem nova majoração da pena-base.

Na segunda fase, agravo a pena em 1/6 em razão do réu ser reincidente (processo nº 0002941-44.2010.8.26.0495 – 2ª Vara Criminal de Registro/SP – trânsito em julgado do réu em 15/1/2013 – fl. 73), totalizando uma pena provisória de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Não há atenuantes da pena.

Na derradeira etapa, está presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas, razão esta da majoração da pena do réu em 1/6, perfazendo 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente em crimes dolosos, tendo inclusive cometido novo delito durante o benefício de livramento condicional (concedido em 28/1/2021 – fl. 30). Além disso, não há prova nos autos de que o réu possui atividade remunerada lícita.

Mantenho, desta forma, a pena em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

No que diz respeito ao réu Gabriel Henrique Barbosa da Silva, considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, porque o réu é primário (fls. 76/77). A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, como mencionado, o réu é primário e não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I (agente menor de 21 anos na data do fato – fl. 75). Contudo, não tem esta o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI da Lei

de Drogas, razão esta da majoração da pena do réu em 1/6, perfazendo a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em que pese o acusado ser primário e ter bons antecedentes (fls. 76/77), deve ser levado em consideração o fato de que possui registros na Vara da Infância e Juventude, cumprindo inclusive medida socioeducativa de liberdade assistida pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico ilícito de entorpecentes (nº 1504221-26.2019.8.26.0344 – fls. 179/180), tornando inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, já que flagrante a dedicação à atividade criminosa, mormente por não exercer atividade laborativa lícita como afirmou (fl. 22).

Desta forma, mantenho a pena tal como dosada na terceira fase da dosimetria, tornando assim final a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Pelas condições econômicas dos réus, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu EDVALDO DE LIMA, devidamente qualificado, como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor mínimo legal; e o réu GABRIEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, devidamente qualificado, como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

A pena privativa de liberdade de ambos os réus deve ser cumprida em regime inicial fechado. Tratando-se de crime equiparado a hediondo, que causa consequências gravíssimas à sociedade, alimentando o crime organizado e destruindo as famílias dos dependentes químicos, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, a fim de que sejam atingidos os objetivos de prevenção geral e específica da punição criminal, especialmente pela quantidade razoável de droga apreendida.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim os réus deverão iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, por não terem atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Também não há nos autos a comprovação necessária do requisito subjetivo para eventual detração e determinação do regime inicial de cumprimento da pena.

Anoto que, diante da pena fixada, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

Os réus tiveram a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante (fls. 79/82) com quantidade razoável de entorpecente, de nefasta repercussão social, permanecendo encarcerados durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram a custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva dos réus, que não poderão recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de

Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomendem-se os réus nos presídios em que se encontram recolhidos.

Em face da condenação supra, os sentenciados arcarão com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso sejam beneficiários da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Ademais, conforme o art. 91, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 63, da Lei Federal 11.343/2006, coadunados com o Tema 647 de Repercussão Geral do Excelso Pretório (REx 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17/05/2017), que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens, consistente no depósito judicial de fl. 146.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 3 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA